

1501204-08.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... assim decidiu:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O

tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501204-08.2019.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501204-08.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283442/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7686884 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 22500/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2283442 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 22500/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARIA ELIZA DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

MARIA ELIZA DA SILVA ALVES foi dada como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 28 de setembro de 2.019, por volta das 09h30, na Rodovia SP 300, KM 342, Jardim Guadalajara, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 19.790 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fls. 109), a ré apresentou a defesa preliminar de fls. 113/114.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 26 de janeiro de 2.021 (fls.

125/127).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e a ré foi interrogada (fls. 175/193).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 208/211).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 215/239, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- as provas são frágeis; 3)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 4)- a ré faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 14/15 e pelo laudo pericial de fls. 202/205 (dezoito porções de maconha com peso de 19.790 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos à acusada.

Interrogado na polícia, ela não somente confessou a prática do crime, como também acrescentou que, cerca de trinta dias antes, trouxe de Campo Grande/MS para Belo Horizonte/MG a quantidade de quinze quilos de maconha e recebeu como contrapartida o valor de R\$ 1.500,00 (fls. 08).

Em juízo, a testemunha Kleber Arão Silvério de Souza Costa, policial militar, afirmou ter abordado um ônibus de linha interestadual, que vinha de Campo Grande e com destino para Belo Horizonte. Durante a revista e entrevista aos passageiros, a ré demonstrou muito nervosismo em razão da aproximação dos policiais. Ao revistar os pertences dela, em uma bolsa próxima a seus pés, constatou que havia dois tijolos de maconha. Retirou-a do ônibus e foi verificar sua bagagem transportando no bagageiro do ônibus. Encontrou, então, mais 18 tijolos de maconha. A ré explicou ter sido contratada por pessoa desconhecida, para que levasse a droga de Campo Grande até, salvo engano, Três Corações, cidade de Minas Gerais, bem como que ganharia dois mil reais pelo transporte. A acusada tinha consigo o ticket referente a bolsa que estava no bagageiro. Ela também disse que, como a bagagem estava muito pesada, resolveu retirar dela dois tijolos e transportá-los em sua bolsa de mão. Não a questionou se ela já havia feito outra viagem para transportar entorpecente. Não se recorda se, na mala que estava no bagageiro, havia outros itens, além da droga. Não se lembra se havia roupas ou utensílios. Também não se recorda se, no banco ao lado da ré, havia outra pessoa. Todos os passageiros e bagagens foram revistados (fls. 176/180).

A testemunha Wallace Gama Santos, também policial militar, disse ter abordado um ônibus interestadual, que vinha de Mato Grosso com destino a Minas Gerais. Durante entrevista com os passageiros e revista, seu parceiro notou a presença de dois tijolos de maconha em uma bolsa. Foi constatada, por meio do ticket e mediante confirmação do motorista, a existência de uma outra bagagem da mesma passageira. Na referida bagagem, havia mais dezesseis tijolos de maconha. A ré, indagada, disse ter retirado a droga em Campo Grande e que a levaria até Três Corações, em Minas Gerais. Ela explicou ainda que receberia dois mil reais pelo transporte e que encontraria uma pessoa na rodoviária, a qual estava incumbida de pegar a droga e lhe pagar. A bolsa estava perto dos pés da acusada. Assim que encontrado o entorpecente na bolsa, ela admitiu que lhe pertencia. A ré acompanhou a revista da bagagem que estava no compartimento de bagagens. Acredita que não foi perguntado para ela se já havia feito transporte de droga anteriormente (fls. 182/184).

Interrogada em juízo, a ré confessou o delito. Levava a droga na bagagem de mão e na outra que estava no bagageiro. Portava cerca de dezenove ou vinte tabletes.

Pegou o entorpecente em Campo Grande, cidade onde reside. Não se recorda qual seria o local de destino do material transportado, pois o fato ocorreu faz tempo.

Acredita que o destino seria Minas Gerais. O ônibus passaria por São Paulo e iria para Minas Gerais. Aceitou transportar o entorpecente pois estava passando dificuldades, já que é mãe solteira e tem três filhos. Receberia dois mil reais pelo serviço. Não havia realizado transporte de drogas antes. Foi a primeira e

única vez que praticou tal delito. Não disse na delegacia que já tinha levado drogas para Belo Horizonte em oportunidade anterior. Atualmente, está trabalhando. Seus filhos tem dez, nove e um ano de idade. Todos dependem dela para o sustento (fls. 186/192).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, a ré confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido a ré insincera ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

“Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário.” (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que encontraram dois tijolos de maconha na bagagem de mão da acusada e outros dezoito tijolos da mesma droga na bagagem transportada no compartimento próprio do ônibus e também a ela pertencente.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Assim, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem comprovados.

Quanto à causa de aumento de pena, restou igualmente comprovada pois, na fase policial, a ré declarou que levaria a droga de Campo Grande/MS para Três Corações/MG. E, em juízo, embora ela tenha dito ter esquecido a cidade de destino, mencionou que pegou a droga em Campo Grande/MS e que o ônibus tinha como destino o Estado de Minas Gerais.

Enfim, tendo a acusada partido de Campo Grande/MS e tendo sido abordado em território paulista, não há dúvida que praticava o tráfico entre Estados da Federação.

Em suma, deve a ré ser condenada por crime de tráfico.

Passa-se à aplicação da pena.

A ré não tem antecedentes criminais (fls. 76).

No entanto, em razão da grande quantidade de droga apreendida, e observado o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas, eleva-se a pena base na proporção de um quinto, resultando em seis anos de reclusão, mais seiscentos dias-multa.

Presente, no entanto, a atenuante da confissão.

Assim, reconduz-se a pena para o mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Não é possível retroceder o "quantum" da reprimenda para montante inferior a tal limite, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06.

Em razão disso, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Primeiro, porque, quando ouvida na fase policial, a acusada declarou já ter feito outro transporte de Campo/MS para Belo Horizonte/MG em ocasião anterior, quando levou 15 quilos de maconha e recebeu R\$ 1.500,00 pelo serviço.

A afirmação assim feita perante a autoridade policial deve ser considerada verídica pois, em juízo, a acusada declarou não se lembrar para onde iria quando detida em flagrante.

Contudo, não há como conceber que pessoa que viaja uma única vez na vida para transportar grande quantidade de droga de um Estado para outro e, mais do que isso, acaba presa em flagrante, esqueça-se o local de seu destino.

Tudo leva a crer, pois, que a acusada já tinha protagonizado a mesma forma de conduta anteriormente pois, somente assim, é possível entender sua afirmação de que não se lembrava para onde estava indo quando foi presa em flagrante. Vale dizer: ela certamente fez confusão quanto a outro (s) destino (s) para o qual já houvera se dirigido anteriormente.

Conclui-se, pois, tratar-se de agente dedicada a atividade criminosa.

No entanto, ainda que assim não fosse, deve-se ponderar ser inegável que a acusada sabia estar realizando ato próprio de uma grande cadeia criminosa. Ou seja: ela tinha plena ciência de que estava transportando droga a partir de um Estado da Federação que faz divisa com países de onde se extrai a respectiva matéria-prima do entorpecente para um centro consumidor e mesmo redistribuidor.

Pode-se afirmar, pois, que se sabia estar praticando ato inerente a uma associação criminosa.

É certo que não se pode considerá-la integrante de associação criminosa, haja vista que o tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11343/2006 exige, para sua caracterização, o "elemento subjetivo no tipo (finalidade especial do agente)", de modo que o delito em questão somente se configura quando presente "a vontade livre e consciente de duas ou mais pessoas reunirem-se com estabilidade, tendo a finalidade especial de cometer um ou mais delitos de tráfico" (Fernando Capez, "Curso de Direito Penal - Legislação Penal Especial", Volume 4, Editora Saraiva, 2ª edição, 2007, p. 723).

Na hipótese "sub judice", os elementos de convicção não permitem afirmar a presença da finalidade de reunir-se "com estabilidade".

Mesmo não se podendo afirmar que a acusada integrava organização criminosa, entende o juízo que o privilégio é incabível em razão da robusta quantidade de droga transportada e demais circunstâncias do caso.

É certo que, segundo entendimento estabelecido pelos Tribunais Superiores, a quantidade e/ou natureza da droga não podem ser invocadas nas duas fases de aplicação da pena (pena base e causa de diminuição), sob pena de "bis in idem".

Veja-se, à propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.

CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira

etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto.

2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. Ademais, aplicar qualquer fração de diminuição diversa daquela imposta pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente – quatro anos e dois meses de reclusão – afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

4. Ordem denegada." (HC 109193 / MG, j. 19/12/2013, Sessão Plenária, relator Ministro Teori Zavascki).

Embora este juízo venha invariavelmente seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, entende-se que, na situação em tela, outro deve ser o posicionamento, pois a questão "sub judice" ainda demanda maiores indagações e necessita de reanálise à luz da superveniência de entendimento de que o tráfico privilegiado não configura crime equiparado a hediondo.

Anote-se não ser lógico afirmar que levar em conta a quantidade e/ou natureza da droga nas duas fases de fixação da pena configura "bis in idem".

Afinal, tal circunstância presta-se apenas à elevação da pena-base, na forma do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, e não para qualquer outro aumento, mas apenas a impedir a diminuição, na terceira fase.

Isto, aliás, é o que decorre da lógica, na medida em que seria evidente contrassenso considerar que a apreensão de grande quantidade de droga serviria para elevação da pena-base (maior reprovabilidade da conduta) e, ao mesmo tempo, não impedisse a redução da pena na terceira fase.

Cite-se, por exemplo, tráfico cometido por agente primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado a atividade criminosa, no qual a quantidade de droga apreendida redunde no aumento da pena-base na proporção de um sexto.

Nessa primeira solução, como se levou em conta a quantidade de entorpecente na primeira fase, não poderia ela ser considerada na terceira, ou seja, deveria ocorrer a redução da pena na fração de dois terços por força do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Ocorre que, na mesma situação, uma segunda solução consistiria em o magistrado deixar de levar em conta tal circunstância na primeira fase, o que o autorizaria a considerá-la na terceira, diminuindo a pena na fração de apenas um sexto.

Ter-se-ia, então, o seguinte quadro: na primeira solução (aumento da pena base de um sexto e aplicação da causa de diminuição em dois terços), embora reconhecida a maior reprovabilidade da conduta (externada pela elevação da pena base), a sanção resultante seria inferior à obtida na segunda solução, em que não se levou em conta a maior reprovabilidade da conduta em face da quantidade de entorpecente (não elevação da pena base).

Ou seja: conduta considerada mais reprovável estaria sendo punida menos severamente do que outra considerada menos reprovável.

Veja-se, outrossim, que a reincidência do agente presta-se, na segunda fase, a agravar a pena e, ao mesmo tempo, a impedir a redução na terceira fase.

Nem por isso, cogita-se de "bis in idem".

Da mesma forma, a primariedade e ausência de antecedentes podem ser levadas em conta na primeira fase de aplicação da pena, para estabelecê-la no mínimo legal e, ao mesmo tempo, também na terceira, para autorizar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

E também aí não se fala em "bis in idem".

Portanto, do ponto de vista lógico, uma circunstância que determina o aumento de pena deve prestar-se a impedir sua diminuição (e não para elevá-la novamente,

quando, aí sim, ter-se-ia "bis in idem"), assim como a primariedade e bons antecedentes impedem o acréscimo de sanção na fixação da pena base e, ao mesmo tempo, importam na redução da reprimenda na terceira fase. Prosseguindo, afirma-se, com todo respeito, que o posicionamento dos Tribunais Superiores carece de nova análise na medida em que os mesmos órgãos jurisdicionais passaram a considerar o tráfico privilegiado não mais como equiparado a hediondo, e sim como crime comum, com as benesses daí decorrentes. Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, datado de 23/06/2016, relatora Ministra Cármen Lúcia, em Sessão Plenária, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida."

A análise do tema deve partir do disposto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, do seguinte teor: "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,".

Segundo a doutrina, "hediondo é algo que causa horror ou repulsa, provoca reação de grande indignação moral. Ao prescrever que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia aqueles definidos como hediondos, o art. 5º, XLIII, da CF pretendeu criar uma categoria de crimes "mais intoleráveis" dentro do ordenamento jurídico, sendo que a reprovabilidade a essas condutas seria, em tese, demonstrada através da resposta penal mais dura (penas elevadas, supressão de garantias individuais)" (Leonardo Sica, em "Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional", Dimitri Dimoulis: Coordenador-geral, Editora Saraiva, 2ª edição, 2012, p. 117).

Da mesma forma, tem-se ensinado que "o constituinte, ao tempo em que impôs, desde logo, a criminalização da prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e do terrorismo, predefiniu-lhes um regime penal mais rigoroso, considerando-os delitos insuscetíveis de fiança, graça e anistia. Paralelamente, projetou essas mesmas vedações aos crimes que o legislador, também por obrigação constitucional, viesse a definir como 'hediondos'," (Luciano Feldens, em "Comentários à Constituição do Brasil", Coordenadores: J J Gomes Canotilho e outros, Editoras Saraiva, Almedina e IDP, 2ª edição, 2018, p. 423).

Daí decorre que a Constituição Federal delinhou uma "arquitetura constitucional na qual há duas extremidades: de um lado, os crimes hediondos e equiparados, merecedores de tratamento rígido, e de outro lado as infrações penais de menor potencial ofensiva (art. 98, inc. I), nas quais se evita a pena privativa de liberdade, com a previsão de benefícios e institutos despenalizadores. Os delitos alocados entre essas extremidades representam a criminalidade comum, à qual deve ser dispensado um tratamento de igual natureza, ou seja, nem extremamente rígido nem muito grave" (Cleber Masson, em "Constituição Federal Comentada", Editora Forense, 2018, p. 189).

Como se vê, a Constituição Federal determinou que haja tratamento penal mais rigoroso para determinados crimes, dentre os quais o tráfico de drogas.

No julgamento do Habeas Corpus n. 118533/MS (em que se reconheceu o tráfico privilegiado como crime comum e não hediondo), o Ministro Gilmar Mendes sustentou que ao legislador ordinário cabe espaço de conformação para deixar de reconduzir condutas com menor lesividade, as quais se enquadrariam nos crimes descritos no

artigo 50, inciso XLIII, da Constituição Federal, ao tratamento mais rigoroso nele previsto, haja vista que a reação estatal deve ser proporcional ao injusto. Exemplificou com o disposto no § 3o do artigo 33 da Lei Antidrogas, que prevê a conduta de "Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem", valorada pelo legislador como de menor potencial ofensivo.

Prosseguiu mencionando que o legislador optou por considerar o tráfico privilegiado como não equiparado a hediondo, pois o artigo 44 da Lei n. 11343/2006, fez menção ao artigo 33, caput e § 1o, mas não ao § 4o.

Concluiu, em seguida, que o legislador podia se afastar do regime constitucional na hipótese prevista no § 4o do artigo 33, pois levou em conta o caráter episódico ou isolado do envolvimento com o crime, em que a conduta não se estende para além de uma única oportunidade.

Seguindo a mesma lógica, o Ministro Edson Fachin, em voto-vista, alterou seu posicionamento anterior e passou também a sustentar a existência de liberdade de conformação do legislador no tocante à previsão de figuras penais de tráfico que não se submetam ao regime dos crimes equiparados a hediondos, pois a determinação constitucional deve ser compreendida à luz da individualização da pena, cuja materialização primeira recai sobre a lei ordinária, conforme artigo 50, inciso XLVI - "a lei regulará a individualização da pena...".

Ressaltou o Ministro Fachin que a discricionariedade legislativa não significa (...) que a opção do legislador esteja, de forma absoluta, imune ao crivo do controle judicial", bem como salientou que o princípio da proporcionalidade, que materializa a vedação ao excesso, pode legitimar de forma excepcional o controle jurisdicional, mormente nas hipóteses em que se tem atingido o direito de liberdade de locomoção.

Ponderou, mais, que o emprego do juízo de proporcionalidade "não deve atuar de modo desvinculado do cenário técnico-normativo. Vale dizer, não se admite que inflexões meramente subjetivas do julgador, ainda que sob a envornizada roupagem normativo-principlológica, sirvam como fundamento jurídico da definição do âmbito de incidência normativa. Assim não fosse, o Estado-Juiz, a pretexto de investigar a juridicidade da lei, transformar-se-ia em juiz da discricionariedade legislativa, avaliando as razões políticas que deram azo ao ato normativo".

Assim, segundo o Ministro Edson Fachin, o juízo de proporcionalidade, quando implementado pelo Poder Judiciário, deve observar como premissas as demais decisões políticas tomadas pelo legislador.

Por consectário, prossegue o Ministro, e como decorrência do princípio da unidade, é "indispensável que o ordenamento jurídico seja compreendido à luz de uma interpretação sistemática direcionada a conferir integridade ao conjunto de normas emanadas do legislativo", o que impõe ao intérprete a tarefa de buscar solução que mantenha a higidez do sistema normativo.

Depois de examinar o conceito de tipicidade conglobante, o Ministro do STF concluiu que a definição de hediondez, "decorrente da maior gravidade ou repugnância do delito, também se submete a um juízo conglobante", ou seja, deve-se aferir a hediondez em consonância com a ordem jurídica globalmente considerada.

Após citar lição de Beccaria (segundo a qual deve haver proporção entre os delitos e as penas e, "se dois crimes atingem desigualmente a sociedade" e "recebem o mesmo castigo, o homem inclinado ao crime, não tendo que temer uma pena maior para o crime mais monstruoso, decidir-se-á mais facilmente pelo delito que lhe seja mais vantajoso"), o Ministro Fachin observou que a quantidade de pena cominada é indicativa da intensidade do juízo político feito pelo legislador quanto à gravidade do crime e, já agora com base em Mariangela Gama de Magalhães, apontou que essa mesma circunstância "fundamenta e constitui a hierarquia material dos valores penalmente protegidos".

E, considerando que a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas permite a redução da reprimenda até para um ano e oito meses de reclusão (que sequer ultrapassa o marco definidor das infrações de menor potencial ofensivo), concluiu que equiparar o tratamento dado ao tráfico privilegiado ao dispensado aos crimes hediondos configuraria desproporcionalidade. Por outras

palavras, "não observaria a Constituição e a unidade do sistema jurídico a norma que atribuisse hediondez dissociada das demais nuances da infração penal, as quais, repita-se, derivam das demais decisões políticas do próprio legislador. Nesse contexto, a partir de um juízo conglobante, compreendo que não se verifica hipótese de hediondez equiparada."

Finalizada a exposição sucinta dos votos dos Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, pode-se sustentar que praticamente os mesmos argumentos que serviram de base à conclusão de que o tráfico privilegiado não constitui crime hediondo prestam-se da mesma forma para fundamentar a tese de que a grande quantidade de droga apreendida, associada às demais circunstâncias do caso, impede a aplicação da causa de diminuição na hipótese destes autos.

Isto porque, se, por um lado, o princípio da proporcionalidade significa a proibição do excesso, por outro também quer dizer proibição de proteção deficiente. Não é demais lembrar que a segurança pública, a par de dever do Estado, também é direito de todos (artigo 144, caput, Constituição Federal).

Não se deve olvidar que a não punição de determinadas condutas com o rigor que merecem igualmente não se conforma ao princípio da proporcionalidade, na sua vertente de vedação de proteção deficiente (no caso, à segurança pública, dever do Estado e direito de todos).

Tal ordem de considerações impõe que novamente se traga a tona o disposto no artigo 50, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual, como visto, lista certos crimes e determina que a eles se dê tratamento penal mais rigoroso.

Isto impõe que o legislador ordinário, dentro de seu espaço de conformação, não pode considerar condutas tidas por "mais intoleráveis" ou repulsivas e que maior horror ou indignação moral provocam, ou seja, dotadas de maior reprovabilidade (lição de Leonardo Sica, *supra* transcrita), como sendo de menor potencial ofensivo e de apená-las de forma branda.

Anote-se, à propósito, que a Lei n. 8072/90, em seu artigo 10, ao definir quais crimes são hediondos, preocupou-se em arrolar condutas intoleráveis e, ao mesmo tempo, que atingem bens jurídicos dotados de maior relevância para a sociedade. Bem por isso, não peca pela infringência à vedação da proteção insuficiente.

A se entender de modo contrário, diga-se, o dispositivo constitucional citado se tornaria letra morta e nem mesmo teria razão de existir.

A respeito da interpretação da Constituição, Canotilho pondera que "o recurso ao texto constitucional, não obstante as dificuldades das operações de determinação dos enunciados linguísticos das normas constitucionais, tem este sentido básico no processo metódico de concretização: (1) o conteúdo vinculante da norma constitucional deve ser o conteúdo semântico dos seus enunciados linguísticos, tal como eles são mediatizados pelas convenções linguísticas relevantes; (2) a formulação linguística da norma constitui o limite externo para quaisquer variações de sentido jurídico-constitucionalmente possíveis (função negativa do texto). Como é sabido, considera-se hoje que o significado de um enunciado linguístico é fixado através de convenções linguísticas" ("Direito Constitucional", Livraria Almedina, 6a edição, p. 219).

Nessa ordem de ideias, se o tráfico é equiparado a crimes hediondos (aqueles que, cujo conteúdo semântico derivado de convenção linguística, são os considerados mais intoleráveis, mais repulsivos, os que maior horror e indignação moral causam, mais reprováveis e que ofendem bens jurídicos dignos de resposta mais enérgica através da tutela penal), não é possível que o legislador situe determinadas condutas ligadas a transações de drogas, que sejam dotadas de grande reprovabilidade, dentre os crimes comuns.

Recorde-se que, segundo aquela "arquitetura constitucional", de que fala Cleber Masson, numa das extremidades, há os crimes hediondos e equiparados (merecedores de tratamento mais rígido) e, noutra, os de menor potencial ofensivo (que requerem tratamento mais branda) e, dentre eles, os crimes comuns, aos quais deve ser dispensado tratamento nem extremamente rígido nem muito grave.

Volviendo à situação dos autos, repita-se que, embora não se tenha prova de se estar diante de agente integrante de organização criminosa e se esteja desconsiderando sua dedicação a atividade criminosa, tem-se agente que saiu do Estado de Mato

Grosso do Sul, com destino a Minas Gerais, transportando nada menos do que 19,79 quilogramas de maconha.

Se a ré não se envolveu em associação criminosa, ao menos é certo, como já se disse, que ela sabia muito bem estar realizando ato próprio de uma grande cadeia criminosa, permitindo distribuição em escala de entorpecente num grande centro consumidor e também responsável pela redistribuição do material ilícito, ocasionando, consequentemente, dano de elevada monta à saúde pública e, mesmo de uma forma mais geral, à segurança pública (em razão dos demais crimes que orbitam em torno do tráfico de drogas e que tanta intranquilidade causam ao cidadão, sobretudo àquele mais vulnerável).

Não bastasse, deve-se ainda dizer que a introdução de grande quantidade de droga numa cidade interiorana de médio porte corrobora para a maior ineficiência do trabalho da polícia e mesmo da Justiça Criminal.

Com efeito, tendo tais esferas que despendem tempo e recursos com o grande número de situações de tráfico de drogas no varejo que ocorrem nos limites territoriais de suas atribuições (decorrentes em última análise, diga-se, de condutas como a da acusada, consistente em trazer para tais limites grande quantidade de droga), pouco tempo lhes sobra para se preocupar com a melhor apuração de outros delitos dotados até de maior gravidade em concreto e objetiva, tais como homicídios e roubos a mão armada.

Não é demais lembrar que a taxa de resolução de crimes de homicídio tem sido pequena em praticamente todo o país.

Não é possível que, em tais circunstâncias, e considerando o enunciado semântico derivado do conteúdo linguístico da norma constitucional, conduta da espécie seja enquadrada como crime comum, e não equiparado a hediondo.

Reportando-se às lições do Ministro Edson Fachin, expostas em seu voto no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, não se trata, aqui, de invocar "inflexões meramente subjetivas do julgador", ainda que sob a invernizada roupagem normativo-principiológica", para definir o âmbito de incidência da norma.

Trata-se, isto sim, ainda de acordo com o Ministro, de observar, no juízo de proporcionalidade, premissas estabelecidas pelas decisões políticas tomadas pelo legislador, o qual, no artigo 42 da Lei n. 11343/2006, estabeleceu que a quantidade e natureza da droga devem ser consideradas na fixação da pena, com preponderância ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

Não se deixa de privilegiar, pois, "o princípio da unidade" e a "interpretação sistemática direcionada a conferir integridade ao conjunto de normas emanadas do legislativo".

Nesse ponto, aliás, é novamente Canotilho quem adverte, ainda ao tratar da concretização da norma constitucional, que "o programa normativo não é apenas a soma dos dados linguísticos normativamente relevantes do texto, captados a nível puramente semântico". Outros elementos devem ser considerados, dentre os quais "a sistemática do texto normativo" e a "teleologia do texto" (ob. cit., p. 220).

Sendo assim, a interpretação sistemática e teleológica, a envolver a interpenetração da Lei n. 11343/2006 e do artigo 50, inciso XLIII, da Constituição Federal, permite afirmar que a conduta ora em análise (transporte de grande quantidade de droga do Mato Grosso do Sul para Minas Gerais) deve ser enquadrada como crime equiparado a hediondo, e não crime comum.

Insista-se que, e novamente voltando ao voto do Ministro Edson Fachin, se o legislador não deve ignorar a proporcionalidade entre o delito e a pena e se a quantidade de pena cominada deve refletir a hierarquia material dos valores penalmente protegidos, não é possível apenas de maneira praticamente insignificante a conduta do acusado, origem de severos danos à saúde pública e à segurança pública como um todo, ambos bens jurídicos dotados de estatura constitucional e o primeiro deles, inclusive, erigido como fator de especial proteção penal (artigo 50, inciso XLIII).

Afinal, segundo Beccaria, o homem inclinado ao crime, não tendo que temer uma pena maior para o crime mais monstruoso, decidir-se-á mais facilmente pelo delito que lhe seja mais vantajoso.

O que equivale dizer que, se aquele que é flagrado transportando enorme quantidade

de droga entre Estados da Federação (obtendo, para tanto, remuneração) recebe o mesmo tratamento que aquele que é surpreendido comercializando em via pública porções de entorpecente em quantia apenas razoável (no ponto em que se consideram ambos praticantes de crime comum, não há dúvida de que "o homem inclinado ao crime" irá se decidir pela prática do delito que lhe seja mais vantajoso, ou seja, pela primeira conduta.

Daí que, em resumo, se o tráfico privilegiado não é crime hediondo e sim comum, a ré não pode ser beneficiada com a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Finalizando a questão, entende-se, respeitosamente, que há a necessidade de nova análise do tema pelos Tribunais Superiores.

É certo que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto supra analisado, ressaltou que basta a constatação do envolvimento episódico no tráfico para que o crime deixe de ser considerado hediondo, tal qual se deu no caso submetido a julgamento pela Suprema Corte, em que se tratou do transporte de mais de setecentos e setenta e dois quilos de maconha.

Ocorre, porém, que houve menção por outros Ministros no sentido de que o caso ali decidido não era o ideal para firmar a tese da não hediondez do tráfico privilegiado, mas que mesmo assim o faziam por considerar que a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 já era tema sepultado pelas instâncias inferiores.

Daí, pois, este juízo, ainda insistir no posicionamento ora exposto.

Não havendo outras modificadoras, são definitivas as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Ante o montante da pena aplicada e as demais circunstâncias expostas (que se prestaram a impedir a aplicação do privilégio de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11343/2006 e conducentes à caracterização da maior reprovabilidade da conduta), o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar a ré Maria Eliza da Silva Alves como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11343/2006, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto aos bens apreendidos, são daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA